



**Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales-ITRC**

SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO/LEY 1437 DE 2011

El artículo 84 de la Ley 1437 de 2011, establece que el Silencio Administrativo Positivo se configura *“Solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones legales especiales, el silencio de la administración equivale a decisión positiva. Los términos para que se entienda producida la decisión positiva presunta comienzan a contarse a partir del día en que se presentó la petición o recurso. El acto positivo presunto podrá ser objeto de revocación directa en los términos de este Código”*.

PROCEDIMIENTO PARA INVOCAR EL SILENCIO ADMINISTRATIVO/LEY 1437 DE 2011

El artículo 85 de la Ley 1437 de 2011, señala el procedimiento que se debe seguir para poder invocar el silencio administrativo, especificando que *“La persona que se hallare en las condiciones previstas en las disposiciones legales que establecen el beneficio del silencio administrativo positivo, protocolizará la constancia o copia de que trata el artículo 15, junto con una declaración jurada de no haberle sido notificada la decisión dentro del término previsto. La escritura y sus copias auténticas producirán todos los efectos legales de la decisión favorable que se pidió, y es deber de todas las personas y autoridades reconocerla así. Para efectos de la protocolización de los documentos de que trata este artículo se entenderá que ellos carecen de valor económico”*.

SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO/SENTENCIA CORTE CONSTITUCIONAL

En términos constitucionales se puede definir la figura del silencio administrativo como una herramienta que el legislador ha dispuesto para que el ciudadano pueda: i) hacer valer sus derechos ante la administración de justicia, en el caso del silencio administrativo negativo, por cuanto no puede quedar indefinidamente a la espera de una respuesta por parte del este estatal encargado de resolverla, hecho que hace necesario crear un mecanismo para que pueda acudir ante la misma administración recurriendo el acto ficto o ante la jurisdicción o, ii) ver satisfechos sus derechos ante la omisión de la administración, en el caso del silencio administrativo positivo, en la medida en que el mutismo de aquella concreta en su cabeza un derecho. Sobre las opciones que tiene el ciudadano cuando opera el silencio administrativo negativo ha dicho esta Corporación en forma reiterada: “..., el administrado puede optar por acudir a la jurisdicción o por esperar una respuesta efectiva de la Administración, sin que esta última opción, que es un desarrollo del derecho de petición, pueda acarrearle consecuencias adversas, como sería la de que a partir del momento previsto para la operancia del silencio administrativo se contabilice el término de prescripción o de caducidad de la respectiva acción”. De esta manera, si bien se podría considerar que en el marco del Estado Social de Derecho la administración está en la obligación de dar respuesta oportuna, clara, concreta y de fondo a las solicitudes presentadas por los ciudadanos, en donde la consagración de una ficción sobre la negativa o aceptación de las peticiones pueden ser percibida como contraria a los postulados de la función pública y el respeto por los derechos fundamentales, si se tienen en cuenta que uno de los fines del Estado es garantizar los derechos consagrados en la Constitución y facilitar la participación de todos en las decisiones que lo afectan, artículo 2 constitucional; la Sala no duda en afirmar que esas presunciones resultan un instrumento adecuado para garantizar, entre otros, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, vulnerados por la omisión de la administración al no responder oportunamente los requerimientos elevados por los ciudadanos. Ficción que en los términos de nuestro ordenamiento no exime a la administración de absolver la solicitud, porque el derecho de petición sólo se satisface cuando el Estado profiriere respuestas claras, precisas y de fondo¹.

Dependencia:	Subdirección de Investigaciones Disciplinarias
Número del Proceso:	1704-01-2015-082
Número y fecha del fallo:	Resolución 17317-00027 del 14 de diciembre de 2016
Asunto:	Fallo de primera instancia
Criterio de Selección:	Fallo de primera instancia confirmado en segunda instancia.

¹ Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 52 (parcial) de la Ley 1437 de 2011, *“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”*.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-082**RESOLUCIÓN No. 17317-00027 14 de diciembre de 2016
POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL
PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-082****1. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO**

Una vez concluida la investigación disciplinaria tramitada en el proceso administrativo disciplinario número 1704-01-2015-082, el Subdirector de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC, procede a proferir fallo de primera instancia, conforme a las exigencias del artículo 170 de la Ley 734 de 2002 y de acuerdo a lo que sigue.

2. IDENTIDAD DEL INVESTIGADO

XXXXX, identificado con la cédula de ciudadanía número XXXXX de Villanueva - Guajira, nacido el 19 de febrero de 1968 en la Juaga del Pilar - Guajira, casado, abogado de profesión, trabajador de la DIAN - Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo, Gestor II Código 302 Grado 02, ubicado en el despacho de la seccional para la fecha de los hechos.

3. HECHOS

Al momento de citarse a audiencia, fueron resumidos así:

"La Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo dentro del expediente No. 11 2009 2011 000374 seguido al contribuyente XXXXX, nit 800.050.326-1, impuso sanción en cuantía de \$356.445.000 a través de la Resolución Sanción No. 232412011000119 del 17 de noviembre de 2011, por el hecho sancionable de información o pruebas no suministradas, información suministrada en forma extemporánea o errores en la información, o no corresponde a la solicitada, respecto del impuestos (sic) de renta del año gravable 2009 periodo 1. Contra esta decisión fue interpuesto recurso de reconsideración por parte del representante legal de la sociedad el 19 de enero del año 2012, siendo trasladado para el conocimiento del disciplinado XXXXX el 23 del mismo mes y año, sin que fuera resuelto dentro del término previsto en el artículo 734 del Estatuto Tributario, motivo por el cual mediante Resolución No.900.073 del 10 de febrero de 2015 se declaró oficiosamente el silencio administrativo positivo respecto del recurso de reconsideración anotado.

De otro lado, al contribuyente XXXXX dentro del proceso No. II2007 2010 00439 se impuso sanción en cuantía de \$324.266.000, a través de la Resolución Sanción No. 2324120100000047 del 11 de octubre del año 2010, siendo presentado y radicado un recurso de reconsideración en oportunidad por el afectado en escrito recibido en la seccional a las 17:41 del 13 de diciembre de 2010 con radicado 9519. El documento fue objeto de traslado al despacho de la seccional, en donde la secretaria XXXXX lo entregó al disciplinado XXXXX, el 14 de diciembre siguiente, para lo de su competencia.

Ante la ausencia de respuesta por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante escrito recibido el 27 de junio del año 2012, el contribuyente solicitó la aplicación del silencio administrativo positivo y el levantamiento de las medidas cautelares, petición inicial nuevamente trasladada a conocimiento del disciplinado XXXXX el 29 del mismo mes y año, sin que fuera atendida en oportunidad, por lo que la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica, mediante Resolución No. 900.094 del 16 de febrero de 2015¹⁰, decidió positivamente la solicitud de reconocimiento de silencio administrativo formulada por el contribuyente XXXXX, respecto del recurso de reconsideración interpuesto con el radicado No. 09519 del 13 de diciembre de 2010, quedando sin efecto la Resolución Sanción No. 2324120100000047 del 11 de octubre del año 2010, que impuso sanción en cuantía de \$324.266.000¹¹ al contribuyente."

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-082**4. CARGO FORMULADO**

Al respecto, en el auto de citación a audiencia, se anotó:

"Como síntesis de lo expuesto, las pruebas recaudadas y su correspondiente análisis, así como los demás argumentos desarrollados en la presente determinación, se citará bajo los protocolos del procedimiento verbal disciplinario al disciplinado XXXXX, identificado con la cédula de ciudadanía número XXXXX, en su condición de Gestor II código 302 grado 02, adscrito para la fecha de los hechos materia de investigación al despacho de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo, como presunto autor responsable de la infracción disciplinaria gravísima del numeral 35° del artículo 48 de Ley 734 de 2002, por supuestamente haber dado lugar a la configuración del silencio administrativo, con ocasión a los recursos de reconsideración presentados el 13 de diciembre de 2010, radicado por XXXXX contra la Resolución Sanción No. 232412010000047 del 11 de octubre de 2010, proferida en el expediente II 2007 2010 000439, y del contribuyente XXXXX, contra la Resolución Sanción No. 232412011000119 del 17 de noviembre de 2011, adoptada en el II 2009 2011 000374, escritos que recibió el 14 de diciembre de 2010 y 23 de enero de 2012, sin que fueran resueltos en el término previsto en el artículo 732 del Estatuto Tributario, dando lugar a la declaratoria del silencio administrativo positivo del artículo 734 de la misma normatividad."

**5. ARGUMENTOS DE DEFENSA:
VERSIÓN LIBRE, DESCARGOS Y ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

En sesión de audiencia celebrada el 13 de diciembre del año 2016, a partir de la hora de las 03:00 p.m., el disciplinado XXXXX presentó alegatos de conclusión, demandando ser absuelto del cargo formulado o, en su defecto, se morigere la imputación disciplinaria.

En palabras del disciplinado, la firma de un libro de radicación no implicaba la competencia para resolver el recurso o para adelantar la función secretarial. Por consiguiente, advierte que no tenía la función ni era el competente tanto para resolver los recursos de reconsideración, como para remitirlos al nivel central, primero porque la competencia por la cuantía estaba en el nivel central para el pronunciamiento de fondo, y la comunicación u oficio los hacía su XXXXX, sin olvidar por supuesto que en la seccional no existía ningún grupo formal o informal jurídico y él no era su coordinador, como se ha pretendido dar a entender.

A estas conclusiones llegó después de analizar las pruebas obtenidas posterior a la citación a audiencia, como es la respuesta desde el nivel central Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos, la inspección al libro radicador, los testimonios de XXXXX, XXXXX, XXXXX y XXXXX, evidencias según las cuales es viable resulte absuelto del cargo porque surge evidente no tenía la función secretarial de elaborar los oficios para remitir los recursos con los expedientes, ni la competencia para pronunciarse de fondo porque recaía en el nivel central.

De otro lado, llamó la atención en cuanto a que para el momento en que se configuraron los silencios estaba en un área diferente al despacho, encargado de una división en la seccional, razón por la que mal puede resultar responsable de los hechos, más aun cuando es latente fallaron los controles o resultaron precarios a la hora de garantizar la resolución de los recursos, falencias que vinieron a superarse en la nueva administración cuando se empezó a hacer seguimiento o dejar trazabilidad incluso cuando un asunto cambia de manos en el grupo de apoyo jurídico de la seccional.

6. CONSIDERACIONES DE INSTANCIA:**6.1 RAZONES DE LA DECISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS EN QUE SE BASA****a. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA:**

Este Despacho es competente para proferir el fallo de primera instancia dentro de la presente investigación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 de la Ley 734 de 2002, en

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-082

concordancia con las previsiones del Decreto 4173 del 3 de noviembre de 2011.

En atención a lo ordenado en el Artículo 142 de la Ley 734 de 2002, no se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado, cuya apreciación debe corresponder a las reglas de la sana crítica, según lo establece el Artículo 141 ibídem

De igual manera, deben reunirse de manera conjunta los requisitos de legalidad, ilicitud sustancial y culpabilidad, reglados en los artículos 4, 5 y 13 de la Ley 734 de 2002, los cuales es menester se encuentren debidamente acreditados dentro del sumario a partir de elementos de prueba legalmente allegados al proceso.

6.2 DEL CASO EN CONCRETO

Para efectos de la presente decisión, deben reunirse de manera conjunta los requisitos de legalidad, ilicitud sustancial y culpabilidad, reglados en los artículos 4, 5 y 13 de la Ley 734 de 2002, acreditados a partir de elementos de prueba. Al respecto, el Consejo de Estado precisó:

"De la lectura de los artículos antes transcritos se observa que los elementos que componen la responsabilidad disciplinaria, esto es aquellos que debe acreditar la autoridad disciplinaria a efectos de imponer una sanción son: 1) la tipicidad que se traduce en que los destinatarios de la ley disciplinaria solo pueden ser investigados y sancionados por comportamientos descritos como falta en la ley vigente; 2) la antijuridicidad o ilicitud sustancial, es concebida como la afectación objetiva a los deberes funcionales, esto es sin que sea necesario un daño material de esta manera basta la sola infracción de los deberes contentivos en la carta política, las leyes los reglamentos, los contratos de trabajo, los manuales de funciones para que se configure el injusto disciplinario por lo cual la conducta para que sea considerada sustancialmente ilícita debe atender contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, y 3) la culpabilidad, concebida la posibilidad de exigir otro comportamiento al sujeto disciplinable, la cual solo puede darse por las modalidades de culpa o dolo."

Como es momento de emitir fallo y culminar el juzgamiento del servidor público XXXXX, acusado por la falta disciplinaria del numeral 35° del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, se torna necesario examinar las pruebas recogidas en el proceso y a partir de su persuasión decidir si se le sanciona o se le absuelve. Será lo primero si las evidencias oportuna y legalmente recogidas aportan certeza de que, responsablemente, cometió la conducta disciplinaria que otrora la Subdirección le atribuyó. Lo segundo, es decir la absolución, si no se cumplen los anteriores requisitos, bien porque se muestre su inocencia, ora porque sobre esos factores no se logre el máximo convencimiento.

De la certeza sobre la comisión de la falta

Al disciplinado XXXXX se imputó en el auto de citación a audiencia la comisión de la infracción disciplinaria gravísima del numeral 35° del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, del siguiente tenor:

"35. Dar lugar a la configuración del silencio administrativo."

La tesis de la Subdirección señala que la conducta del disciplinado determinó el acaecimiento del silencio administrativo positivo en los expedientes administrativos II 2009 2011 000374 de XXXXX, y II 2007 2010 00439 contra XXXXX, habida cuenta que no actuó con el cuidado oportuno o siquiera elemental, para garantizar la atención de los recursos por parte del área competente. La antítesis del disciplinado se sustenta sobre su inculpabilidad frente a los hechos, pues funcionalmente no debía resolver los recursos, ni proyectar algún acto u oficio, al no ser coordinador del área jurídica ni cumplir funciones secretariales en el despacho de la seccional.

Hecha esta claridad, la Subdirección encuentra que el caso no plantea controversia por lo relativo a la situación fáctica que constituye el marco del caso, concretamente, el acaecimiento del silencio administrativo, el cual se halla debidamente demostrado, por cuanto existe fotocopia de la Resolución Sanción No. 232412011000119 del 17 de noviembre de 2011 (fl. 117 a 124), proferida

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-082

dentro del expediente II 2009 2011 00374 seguido contra XXXXX, conjuntamente con copia del recurso de reconsideración oportunamente interpuesto por la representante legal del contribuyente (fl. 5 a 20), y del acto administrativo a través del cual, la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, declaró de oficio el silencio administrativo positivo respecto del recurso de reconsideración frente a la resolución sanción anotada (fl. 129 a 131).

De igual modo está demostrado que el 11 de octubre de 2010 se profirió la Resolución Sanción No. 23241201000047 dentro expediente II 2007 2010 439 en contra de XXXXX -ver fl. 650 acta de inspección administrativa-, así como del recurso de reconsideración elevada por el contribuyente el 13 de diciembre del año 2012 (fl. 436 a 441), y de la Resolución No. 900.094 del 16 de febrero de 2015 expedida por la Subdirectora de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN (fl. 503 a 506), accediendo a la solicitud del reconocimiento del silencio administrativo positivo formulada el 27 de junio de 2012 (fl. 442), respecto del recurso de reconsideración impetrado por XXXXX.

Es importante destacar que el artículo 732 del Estatuto Tributario señala que la administración de impuestos dispone de un (1) año para resolver los recursos de reconsideración o reposición, contados a partir de su interposición en debida forma: en el expediente de XXXXX se profirió Resolución Sanción No. 232412011000119 el 17 de noviembre de 2011, se notificó el 26 del mismo mes y año, el recurso de reconsideración se presentó el 19 de enero de 2012, por lo tanto debía resolverse antes del 19 de enero de 2013, y como no fue así el 10 de febrero de 2015 se declaró de oficio el silencio administrativo positivo; el 10 de octubre de 2010 se profirió Resolución Sanción No. 2324120100000047 en el expediente de XXXXX, a quien se notificó el 13 del mismo mes y año, formulando recurso de reconsideración el 13 de diciembre inmediatamente siguiente, inobservando el plazo para resolver, el cual venció el 13 de diciembre de 2011, accediéndose a la solicitud de reconocimiento del silencio administrativo el 16 de febrero de 2015.

A partir de lo anterior, se demuestra más allá de duda razonable la comisión de la infracción disciplinaria gravísima inserta en el numeral 35 del artículo 48 de la ley 734 de 2002 -"Dar lugar a la configuración del silencio administrativo positivo"-

Encontrándose abastecido el presupuesto sobre la certeza frente a la ocurrencia de la falta disciplinaria, impone determinar el mismo nivel de seguridad sobre la responsabilidad del disciplinado XXXXX.

De la certeza de la responsabilidad y la forma de culpabilidad.

Verificada la materialización de la falta disciplinaria, por concurrir los elementos integradores del injusto, es menester examinar si puede atribuirse la falta al disciplinado XXXXX, en calidad de autor con arreglo al principio de culpabilidad del artículo 13 de la Ley 734 de 2002, erradicando toda forma de responsabilidad objetiva, encontrando viable la conclusión de responsabilidad sin asomo de solución distinta.

El numeral 35 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 eleva a categoría de falta disciplinaria gravísima el dar lugar a la configuración el silencio administrativo positivo del artículo 84 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, entendido que el verbo rector se relaciona con los eventos de provocar o de ser causa de que algo suceda, bajo las formas de realización del comportamiento del artículo 27 ibídem, esto es, por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de las funciones.

Se tiene plenamente acreditado al interior de la actuación que los recursos de reconsideración presentados por los contribuyentes XXXXX y XXXXX, posterior a su recibo en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo, fueron efectivamente entregados al disciplinado XXXXX: el primero el 23 de enero del año 2012, según copia del libro de radicaciones del despacho, el cual obra a folio 30, y el segundo, el 14 de diciembre del año 2010, conforme a reproducción del mismo libro visible a folios 655 y 746, aclarando que si bien la fecha fue anotada como 14-12-00, ésta

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-082

corresponde realmente al año 2010, según los registros previos y posteriores que se aprecia en el mismo libro de radicaciones de la correspondencia recibida por el despacho de la seccional.

Posterior a este evento, no fue posible obtener ninguna evidencia documental o testimonial que acreditara la versión del servidor XXXXX, en el sentido que, presuntamente, devolvió los escritos de recurso de reconsideración a quienes fungían como secretarías del despacho para ese momento, concretamente las señoras XXXXX y XXXXX, aclarando que la primera reemplazaba por vacaciones a la titular del momento XXXXX, conforme a testimonio ofrecido por la señora XXXXX el 20 de junio del año que avanza (fl. 400-402).

Es a partir de esta situación que para la Subdirección resulta evidente que el señor XXXXX resulta responsable de la imputación disciplinaria formulada en el auto de citación a audiencia, pues más allá que hubiese fungido o no como coordinador, que existiera o no un grupo informal jurídico en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo, situación que al parecer era así según los testimonios de XXXXX (folio 735) y XXXXX, para este Despacho resulta diáfano que lo pertinente era que el disciplinado, al menos, hubiese hecho entrega efectiva y en forma directa de los escritos contentivos del recurso de reconsideración a quien normalmente proyectada los oficios remisorios, para que éste a su vez elaborara la comunicación remisoria para firma del administrador de la época. En efecto, según el reporte de la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN (fl. 822-836), así como también se concluye de los argumentos conclusivos del disciplinado, el señor XXXXX era el responsable de la proyección de los oficios dando traslado de recursos de reconsideración al Nivel Central. Si esto era así, no se explica ni se entiende por qué el disciplinado, según sus diligencias de versión libre y espontánea, presuntamente devolvió a la mano al personal de secretaría los memoriales de los recursos, más aún cuando era consciente que existían falencias en el control a los documentos, sobre todo aquellos que no debían ser resueltos en la seccional por no ser de su competencia y supuestamente se devolvían al personal de secretaría. Ello permite inferir que si hubiese regresado los recursos, dejó al albur la suerte de los mismos, porque no ejecutó acción realmente efectiva que garantizara su entrega a quien estaba a cargo de la elaboración del comunicado para trasladar al nivel central de los recursos con los expedientes.

Ahora, igual pudo el disciplinado desarrollar las actividades relacionadas por el Director Seccional de la época, doctor XXXXX, las cuales fueron reiteradas parcialmente por el testigo XXXXX (fl. 851) en el sentido que, cuando un asunto escapaba a la competencia de la seccional, se devolvían los escritos con el correspondiente oficio para firma y envío del administrador local (fl. 735 vuelto y 736), situación que para la Subdirección garantizaba o, al menos, disminuía el riesgo de desatención oportuna de los recursos de reconsideración, peligro que finalmente se materializó para los casos en concreto, por vencimiento del plazo del artículo 732 del Estatuto Tributario, sin pronunciamiento de la administración, dando lugar a la configuración del silencio administrativo positivo del artículo 84 del CPACA.

Ahora bien, es indiscutible que las funciones secretariales estaban en cabeza de las servidoras XXXXX y XXXXX, para la época de los hechos, así como que el señor XXXXX, quien proyectaba los oficios remisorios de recursos al nivel central para su resolución, igual resulta innegable que otras funciones propias del disciplinado le imponían o permitían direccionar al competente asuntos fuera de su órbita, como era el caso de los recursos de reconsideración citados en esta decisión. Así se desprende, por lo menos, de las funciones que como Gestor Jurídico debía cumplir, es decir analizar, establecer la competencia y direccionar al competente y si es del caso proyectar respuesta remitiendo la doctrina vigente o remitir al competente (fl. 843 numeral 8 y folio 844, numeral 9) o incluso coordinar las labores de apoyo administrativo con el fin de facilitar y agilizar el fallo de los recursos jurídicos (fl. 844 numeral 10), de las cuales pudo echar mano para garantizar la entrega de los escritos al señor XXXXX.

Es inaceptable entonces que el señor XXXXX se limitara, por así decirlo, a devolver a las señoras XXXXX y XXXXX los memoriales de los recursos de reconsideración, cuando no gozaban de la formación profesional para determinar la competencia de la seccional, además de conocer que la remisión - elaboración del oficio - normalmente la cumplía un funcionario de mayor nivel que aquellas, al igual adscrito al despacho y no a trabajadoras con rol de operador de procesos para la secretaría

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-082

de la seccional.

No puede dejar de resaltar la Subdirección que de las resultas de la diligencia de inspección administrativa al libro de radicaciones de correspondencia del despacho de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo, se puede concluir que el doctor XXXXX tenía una labor destacada entre los abogados de apoyo, porque como se evidenció recibía los escritos de recursos de reconsideración, independientemente fueran de competencia de la seccional o del Nivel Central para su resolución, y en caso negativo lo direccionaba a su compañero XXXXX, quien se encargada de elaborar el oficio para la firma del administrador.

Así pues, que la Subdirección encuentra que el disciplinado XXXXX, con su actuación contribuyó efectiva y eficazmente o fue causa fundante de la configuración del silencio administrativo positivo acaecido y reconocido en los expedientes II 2009 2011 000374 de XXXXX, y II 2007 2010 000439 de XXXXX, habida cuenta que por su actuar particularmente descuidado e influido por una inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común habría imprimido a sus actuaciones, al no garantizar de forma eficiente la remisión de los escritos con los expedientes al nivel central, pese a su conocimiento de que la elaboración de los oficios remisorios correspondía a XXXXX.

Al momento de citar a audiencia, se anotó que la forma de culpabilidad enmarcaba en la descripción de la culpa gravísima del parágrafo del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, concretamente, bajo la categoría de la desatención elemental, en el entendido que el disciplinado no ejecutó la actividad que cualquier funcionario diligente hubiese efectuado, como alertar al director seccional, a otro profesional si él no era el coordinador, o al menos elaborar el oficio para pasarlo al director conjuntamente con el escrito para asegurar su remisión al área competente; no obstante, habiendo sopesado el acervo probatorio de manera integral y al efectuar una visualización minuciosa del contexto esencial de la problemática, el Despacho considera que la conducta del disciplinado se enmarca realmente en una inobservancia del cuidado necesario, lo que determinaría el cambio de la forma de culpabilidad de una culpa gravísima a una culpa grave, bajo las condiciones establecidas en el numeral 9 del artículo 43 de la ley disciplinaria.

En efecto, frente a los recursos de reconsideración presentados en oportunidad por los contribuyentes XXXXX, y de XXXXX, advertida la incompetencia para resolverlos en la seccional de Sincelejo, lo obvio era que el disciplinado XXXXX proyectara un oficio para su remisión al nivel central con el expediente; más sin embargo, dado que la tarea era del resorte de su compañero XXXXX, resultaba entonces imprescindible que lo entregara directamente a él, o que diera una instrucción precisa a las señoras XXXXX y XXXXX para asegurar el envío de la actuación al competente.

Sin embargo, obsérvese que el disciplinado no desplegó ninguna acción que garantizara la oportuna resolución de los recursos, pues ninguna prueba se aportó ni obtuvo el despacho, incluso al parecer el recurso interpuesto por el contribuyente XXXXX, al que depositó en un sobre antes de salir a vacaciones en el año 2010, conforme a testimonio de la señora XXXXX, y sea que lo hubiese devuelto o que lo dejara en su puesto de trabajo previo a disfrutar de un periodo de vacaciones, lejos está de la conducta idónea, propia y esperada de un servidor público experimentado y conocedor de la importancia tanto del escrito como su resolución en término para la preservación de los intereses de la administración frente a la obligación generada por la omisión del contribuyente.

Bajo esa perspectiva y como conclusión, está demostrado con certeza que el servidor público XXXXX, si hubiese enmarcado su conducta dentro de la observancia del cuidado necesario que debió proveer al trámite una vez recibido cada uno de los recursos, se hubiese evitado la configuración del silencio administrativo positivo dentro de los expedientes II 2009 2011 000374 de XXXXX, y II 2007 2010 000439 de XXXXX, adelantados en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo, al no haber ejecutado las acciones idóneas que garantizaran la resolución de los recursos de reconsideración impetrados en oportunidad por los contribuyentes contra las resoluciones sanción proferidas por la administración.

Así, se ha verificado que la acción juzgada es típica, por subsumirse la conducta del trabajador dentro del modelo de falta, pero además comprobada la responsabilidad en la generación de la infracción,

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-082

por lo que solo resta anotar que la acción es antijurídica, pues afectó el deber funcional sin justificación alguna.

De la certeza sobre la ilicitud sustancial

La ley disciplinaria tiene como finalidad específica la prevención y buena de marcha de la gestión pública, así como la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con las conductas que los servidores públicos que los afecten o pongan en peligro, desarrollados bajo los principios del artículo 22 de la Ley 734 de 2002 (moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia) sobre la base de los deberes funcionales propios asociados al cargo o la función. La ilicitud sustancial disciplinaria debe ser entendida como la afectación sustancial de los deberes funcionales, siempre que ello implique el desconocimiento de los principios que rigen la función pública.

Siendo así, se reviste de ilicitud sustancial la conducta del señor XXXXX porque afectó trascendientemente la administración, su falta de eficacia y eficiencia se reiteró inexplicablemente de un año a otro, en dos expedientes tributarios distintos, derivando en la pérdida para la entidad de la posibilidad final de recaudar los valores derivados del proceso de determinación e imposición de las sanciones a los contribuyentes XXXXX y XXXXX, que sumados arrojaban la no despreciable cifra de \$680.710.800.

Como abogado de profesión, gestor jurídico, asistente y abogado de la vía gubernativa adscrito al despacho de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo, destacado en el manejo de recursos de reconsideración en la seccional, al ser el receptor inicial de los mismos en el despacho, conocía ampliamente la importancia de la resolución oportuna de los recursos, su entrega o remisión al o a las áreas competentes tanto a nivel local como central, por consiguiente, estas condiciones le imponían la tarea de actuar eficaz y eficientemente para garantizar la gestión de la DIAN respecto de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, luego, resulta injustificable que, en dos oportunidades, con un año de diferencia y habiendo sido el receptor de la totalidad de los recursos y conocedor del protocolo interno para su atención a nivel local y central, no hubiese actuado con la atención necesaria y elemental para el envío de los mismos al competente.

A lo anterior se suma una situación debidamente comprobada en el expediente ya que el contribuyente XXXXX solicitó para su caso la aplicación del silencio administrativo positivo mediante un escrito que no obstante haber sido igualmente recibido por el disciplinado, la solicitud así presentada nunca se resolvió. Esta particularidad generó una señal de alerta que no impidió que la situación se materializara nuevamente, pero en el caso del contribuyente XXXXX.

Colofón de lo expuesto, quedó quebrada la presunción de inocencia del señor XXXXX y por eso, demostrada con certeza la comisión de la falta, el compromiso de su responsabilidad y la ilicitud del comportamiento, la Subdirección lo declara responsable de la infracción disciplinaria del numeral 35 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

DE LA CONTESTACIÓN A LOS ARGUMENTOS DEL INVESTIGADO

Aunque a lo largo de esta decisión han sido analizados y respondidos los argumentos conclusivos formulados por el disciplinado, la Subdirección procede a referirse independientemente a los mismos en el presente acápite.

Sea lo primero indicar que el despacho no es ajeno a los conceptos de deber funcional y competencia, y entiende difieren el uno del otro en el ámbito disciplinario. Mientras el primero hace referencia a las funciones propias de los servidores públicos para un cargo determinado, la segunda se relaciona con la atribución jurídica otorgada a ciertos y especiales órganos de la administración para resolver determinados asuntos, sea por la calidad de los intervinientes, la cuantía de los asuntos en discusión o el tipo de la materia en estudio, entre otros aspectos.

En el caso materia del proceso, como ya se anotó, no se desconoce que el disciplinado no cumplía

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-082

funciones de índole secretarial, pues su cargo era de gestor; sin embargo, otras funciones le permitían, o si se quiere le imponían, la obligación de actuar con la debida y oportuna gestión, de forma tal que se garantizara la resolución en término y por el competente los recursos de reconsideración, ya fuera haciendo llegar a su compañero XXXXX los memoriales para que este elaborara los oficios, o elaborándoles el mismo para la firma del administrador.

Para la Subdirección eran las acciones que elementalmente debía cumplir el disciplinado, y no haberse limitado a devolver los escritos a las secretarías, si es que realmente llegó a hacerlo, para que éstas se encargaran de trasladar los memoriales al señor XXXXX. No se trata que el disciplinado fuera un todo, en él convergieran las funciones de recepción, estudio, proyección y resolución, sino que siendo el abogado destacada para el manejo de los recursos, por lo menos fuera efectivo y eficaz, como lo fue en los otros recursos recibidos, con los memoriales de recurso de reconsideración de los contribuyentes XXXXX e XXXXX.

Aunque en el ambiente queda la sensación de que el control a la correspondencia, y especialmente a los recursos no era totalmente efectiva ente los años 2010 y 2011 en el despacho de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo, no se entiende por qué el disciplinado fue parte del problema y no de la solución y dejó a la suerte que los recursos llegaran a las manos del señor XXXXX, cuando lo mínimo era que él directamente le entregara a la mano los escritos, para que éste después de la revisión que con toda seguridad hacía XXXXX elaborara la comunicación remisoría.

De los testimonios de XXXXX, XXXXX, XXXXX, y XXXXX, así como de los reportes documentales del área de la Subdirección Jurídica y los resultados de las inspecciones administrativas a su hoja de vida y al libro radicador de correspondencia el disciplinado presenta su interpretación personal y las conclusiones que, a su juicio, demuestran su inocencia en los hechos materia del proceso y la necesidad de absolverlo del cargo imputado, planteamientos que la Subdirección obviamente no comparte y por ello llega a una conclusión diferente.

Como ya anotó en oportunidad, para dar lugar a la falta disciplinaria gravísima del numeral 35 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, se requiere que la acción u omisión del servidor público contribuya a la configuración del silencio administrativo, para lo cual basta con desplegar dolosa o descuidadamente alguna acción o dejar de ejecutar alguna actividad que lleve al resultado. La competencia específica o la función determinada puede incluso no estar presente, solamente es necesario que de alguna forma la intervención activa o pasiva del funcionario público lleve al fenómeno del silencio positivo.

Y eso es precisamente lo latente, presente y demostrado en el expediente disciplinario: XXXXX era el abogado destacado en el despacho de la seccional, a él llegaban en general los asuntos de mayor trascendencia jurídica, como los recursos de reconsideración contra las resoluciones sanción, después de evaluar si se resolvían en la seccional o no lo entregada a su compañero XXXXX para que elaborara el oficio remisorio, como sucedió en los demás casos. En los eventos de XXXXX e XXXXX, actuó diferente, no siguió la misma regla de comportamiento y por razones que no se explican alteró el curso normal del procedimiento en el despacho de la seccional y descuidadamente, desatentamente, con el menor grado de atención presuntamente devolvió los escritos al personal de secretaría, para que éste lo entregara a XXXXX, aunque la realidad es que ello no fue así y que los escritos de los recursos quedaron en sus manos y vinieron a encontrarse cuando la nueva administración efectuó una revisión de los asuntos pendientes por resolver, casi tres años después, cuando los presupuestos normativos del silencio administrativo positivo concurrían a favor de los contribuyentes, quienes se vieron favorecidos al no tener que cancelar a la administración las obligaciones establecidas en el proceso de determinación.

Por las anteriores razones esta Subdirección no comparte los planteamientos del disciplinado para ser absuelto del cargo, ni encuentra viabilidad en la variación de la forma de culpabilidad, llegando a la conclusión que deberá mantenerse la imputación conforme al auto de citación a audiencia.

7. DE LA SANCION POR IMPONER

El artículo 44 de la Ley 734 de 2002 indica que el servidor público está sometido a las siguientes

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-082

sanciones:

- Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima.
- Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas.
- Suspensión, para las faltas graves culposas.
- Multa, para las faltas leves dolosas.
- Amonestación escrita, para las faltas leves culposas.
-

Para el efecto de determinar la sanción, se tiene en cuenta que el doctor XXXXX es responsable y por consecuencia sancionado por la falta disciplinaria gravísima del numeral 35° del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que originalmente tiene prevista sanción de destitución e inhabilidad general, con término de diez a veinte años - art. 46 C.D.U.; no obstante, considera el Despacho que la culpabilidad se circunscribe, conforme a lo analizado a una culpa grave por inobservancia del cuidado necesario, lo cual determina en aplicación del artículo 43, numeral 9, que la falta sea considerada como grave y realizada con culpa grave, por lo que la sanción a imponerse y en consonancia con los artículos 45 y 46 de la Ley Disciplinaria será la de SUSPENSION en el ejercicio del cargo por el término de SEIS (6) MESES, habida cuenta que el silencio administrativo positivo se configuró en dos expedientes tributarios diferentes

Se destaca por la Subdirección que, en todo caso, no concurren antecedentes disciplinarios o fiscales en su contra, ni elemento que impongan concluir que actuaba de manera ineficiente en el desempeño de su cargo o función durante su vinculación con la DIAN, a excepción de los eventos que concitaron la atención de la Subdirección; si bien es cierto no confesó la comisión de la falta antes de la formulación de cargos, igual sus exculpaciones tampoco trataron infundadamente de atribuirle la responsabilidad a un tercero, sino aprovechar una circunstancia particular del despacho, la ausencia de registro de devolución, para tratar de eludir su responsabilidad en los hechos.

De igual manera y atendiendo la existencia de un posible detrimento patrimonial al Estado, ante la ocurrencia de los hechos objeto de fallo, este Despacho dispondrá adicionalmente, la compulsa de copias a la Contraloría General de la República.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA de XXXXX, DIAN , identificado con la cédula de ciudadanía número 17.973.278, en su condición de Gestor II 302 02 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, como autor de la falta disciplinaria gravísima prevista en el numeral 35° del artículo 48 de la ley 734 de 2002, , infracción imputada a título de culpa grave, de conformidad con los argumentos desarrollados en el aparte de consideraciones.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, IMPONER a XXXXX, DIAN , sanción disciplinaria consistente en SUSPENSION por SEIS (6) MESES en el ejercicio del cargo, de conformidad con lo señalado en la parte motiva precedente, teniendo en cuenta las previsiones del artículo 45 inciso final de la Ley 734 de 2002.

TERCERO: NOTIFICAR EN ESTRADOS la presente decisión de conformidad con lo establecido en el artículo 179 de la Ley 734 de 2002, a los sujetos procesales.

CUARTO: ADVERTIR que contra la presente decisión procede el RECURSO DE APELACIÓN, el cual se deberá interponer y sustentar en audiencia.

QUINTO: REMITIR copia de la presente decisión, a la Contraloría General de la República, para que ejerza, si resulta procedente, la actuación fiscal pertinente, al tenor de lo dispuesto en la parte considerativa.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2015-082

SEXTO: En firme la presente decisión, COMUNICARLA en la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con el artículo 174 del Código Disciplinario Único.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE,

Jorge A. Moreno Ponce

JORGE ADRIANO MORENO PONCE
Subdirector de Investigaciones Disciplinarias
UAE Agencia ITRC